

TEORIA GERAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

A Teoria Geral dos Direitos Fundamentais é um assunto prioritariamente doutrinário, mas que tem caído bastante nas provas de concurso. Por se tratar de um assunto mais abstrato, os candidatos têm mais dificuldade de lidar com ele. A seguir, serão trabalhados os seguintes tópicos:

- Características dos direitos fundamentais;
- Evolução dos direitos fundamentais em 1ª, 2ª e 3ª geração;
- A forma como os direitos fundamentais se apresentam: relação vertical, horizontal, diagonal ou transversal.

No passado, esses temas eram cobrados apenas em concursos da carreira jurídica, mas atualmente têm sido cobrados nos níveis superior e médio.

Observa-se a seguinte expressão: o seu direito acaba onde começa o do outro. A limitação de direitos é natural, pois uma pessoa não poderia ter tudo em sacrifício de outras. Nesse ponto, entram as características dos direitos fundamentais.

Para o professor Norberto Bobbio, existem apenas dois direitos absolutos: o direito de não ser torturado e o direito de não ser escravizado. Seja como for, no âmbito do STF, que é o que normalmente é cobrado em provas, não existe direito absoluto.

Quanto à questão da tortura, existe a chamada teoria da bomba-relógio, exemplificada a seguir: uma bomba-relógio está prestes a matar centenas de pessoas, mas apenas uma possui o código para desativá-la. Seria correto torturar o detentor do código para que ele desativasse a bomba? Não, pois a doutrina entende que, mesmo que o sujeito fosse submetido à tortura, não seria possível saber se ele revelaria o código da bomba.

Características

- Relatividade: os direitos fundamentais podem sofrer restrição. Exemplo: a liberdade de expressão e o direito à privacidade que, às vezes, entram em rota de colisão. Nessa circunstância, nenhum deles será declarado inconstitucional, pois são normas originárias, mas haverá a ponderação de interesses no caso concreto.



5m

ANOTAÇÕES

- **Concorrência:** quando os direitos se chocam, é preciso ponderar qual deles cederá espaço para o outro. Exemplo: a Constituição garante o direito de reunião para fins pacíficos, sem armas e em locais abertos ao público. Em relação ao direito de reunião, existe a possibilidade de liberar marchas da maconha? Nesse caso, existe, ao mesmo tempo, a possibilidade de exercício do direito de reunião associado à livre manifestação do pensamento. Ambos incidirão na situação concreta.
- **Imprescritibilidade:** não se fala em perda do direito pelo uso. Contudo, o candidato deve ficar atento aos direitos de cunho patrimonial. Exemplo: o direito de propriedade é um direito fundamental, mas existe o chamado usucapião, de modo que a repercussão patrimonial pode sofrer a perda.
- **Inalienabilidade:** os direitos não podem ser vendidos. A inalienabilidade e a indisponibilidade podem ser trabalhados ao mesmo tempo. Exemplo: os participantes do reality show *Big Brother Brasil* abrem mão da privacidade e da intimidade por um determinado período de tempo. No mundo dos esportes, o direito de imagem pode ser cedido por um jogador. O professor Aragonê cede o direito sobre sua imagem ao Gran Cursos Online em troca de dinheiro.



10m

Na França, havia um circo que exibia um espetáculo em que uma pessoa com nanismo era atirada de um canhão. Isso foi considerado pela justiça uma ofensa à dignidade humana, ainda que o indivíduo que participava do espetáculo discordasse. O direito à vida e à dignidade são indisponíveis.

- **Irrenunciabilidade:** os direitos à vida e à dignidade são indisponíveis. Contudo, os direitos patrimoniais são mais flexíveis. Exemplo: foi noticiado que o cantor Roberto Carlos abriu mão de todos os direitos autorais sobre suas músicas, pois havia repercussão patrimonial.

Obs.: alguns anos atrás, um programa de televisão, chamado *Pânico*, exibia um quadro intitulado Sandálias da Humildade, no qual pares de sandália eram enviados a pessoas supostamente arrogantes. Uma das pessoas escolhidas foi a atriz Carolina Dieckmann, que passou a ser perseguida pelo programa. O aborrecimento provocado pelo programa foi tão grande que a atriz obteve na justiça, via mandado de segurança, uma medida, impedindo a atração de se aproximar dela por no mínimo 200

ANOTAÇÕES

metros. Contudo, o abuso continuou: o programa contratou uma escada magirus, pendurou o calçado na escada e a aproximou da janela da atriz. Trata-se de um claro exemplo do abuso do direito à liberdade de expressão, pois mesmo pessoas públicas têm direito a uma esfera de proteção à privacidade e à intimidade.

- **Historicidade:** alguns anos atrás, um juiz determinou a retirada do ar do aplicativo de mensagens WhatsApp, pois não forneceu os dados dos membros de uma quadrilha durante a apuração de um crime.



15m

Esse tipo de decisão não ocorre na justiça brasileira já há algum tempo, pois o STF entendeu que o direito à internet é fundamental. Além disso, a Emenda n. 115/22 inseriu o inciso LXXIX no art. 5º da Constituição para tratar a proteção de dados como um direito fundamental. Esse é um claro exemplo da historicidade: com o passar do tempo, a sociedade avança, novos direitos vão surgindo, sendo incorporados e, pouco a pouco, inseridos na Constituição. Originalmente, a Constituição previa apenas comunicações telegráficas e não os chamados dados telemáticos. Hoje em dia, quase ninguém recebe telegrama. Assim, na atualidade, é possível falar em proteção de dados com respaldo constitucional.

- **Extensão a pessoas jurídicas:** os direitos fundamentais nascem para proteger os cidadãos contra abusos do Estado. A extensão dos direitos fundamentais a pessoas jurídicas ocorrerá naquilo que couber. Por exemplo, a pessoa jurídica tem nome e dados (fiscais, bancários, telefônicos), mas não tem vida e nem liberdade.

Obs.: assim como a pessoa natural, a pessoa jurídica também tem honra, que se desdobra em honra objetiva e subjetiva. A pessoa jurídica tem honra objetiva: a imagem dela diante da sociedade. Exemplo: o que as pessoas falam do Gran Cursos Online. Apenas pessoas naturais têm compreensão a seu próprio respeito. Trata-se de honra subjetiva.



20m

- **Extensão a estrangeiros:** o *caput* do art. 5º da Constituição garante a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade a brasileiros e estrangeiros residentes no país. Os turistas estrangeiros também usufruem desses direitos. Contudo, esses direitos não se aplicam aos estrangeiros na mesma escala e proporção em que se aplicam aos brasileiros natos. Basta associar com a imagem de uma

ANOTAÇÕES

pirâmide escalonada: no topo, estão os brasileiros natos, no meio, os estrangeiros naturalizados e, na base, encontram-se os estrangeiros. Alguns direitos fundamentais são exclusivos para estrangeiros, como a concessão de asilo político. Brasileiros natos não podem ser extraditados do território brasileiro, mas se estiverem no exterior podem ter a sua extradição pedida pelo Brasil. Os brasileiros naturalizados podem ser extraditados em algumas situações excepcionais previstas na Constituição.

Obs.: com a transformação da sociedade, os animais têm direitos fundamentais? Hoje, ainda não se pode falar em titularidade de direitos fundamentais de animais. Por exemplo, recentemente houve uma ação judicial em que alguns gatos “entraram” na justiça para não serem retirados de um condomínio. Nesse caso, como seria a audiência de conciliação? Quem seria o advogado? Se os gatos perdessem a ação, quem pagaria os honorários? Outros exemplos: julgamento pelo STJ de *habeas corpus* para soltar chimpanzés levados pelo Ibama, que cassou a autorização do dono. Assim, atualmente, ainda prevalece a orientação de que animais não são titulares de direitos fundamentais.



25m



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, julgue os itens seguintes.
Os direitos fundamentais não são absolutos e podem ser restringidos ou limitados por previsão constitucional ou legal, em benefício do interesse social e em observância às bases de proporcionalidade.



COMENTÁRIO

Os direitos fundamentais podem sofrer contenção.

GABARITO

1. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.